Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
17ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent17vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5236863-18.2023.8.21.0001/RS

AUTOR: ADRIANA SANTOS PORTELLA

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

Vistos.

I - Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por ADRIANA SANTOS PORTELLA em face de UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA., narrando, em suma, ser portadora de moléstia referente ao CID J45.1, especificamente asma grave de início tardio, que ocasionou uma uma piora significativa em sua saúde nos últimos meses, sendo e a única alternativa terapêutica o uso do medicamento Tezepelumabe 210mg. Ante à recusa expressa da ré em fornecer o fármaco e eventual negativa judicial para o tratamento, poderá levá-la à óbito. Pleiteia haja o fornecimento do medicamento receitado e fundamenta seus pedidos nos artigos 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor; IN 065 da RN 465/2021 da ANS, RN 428/2017 da ANS e na Lei nº 9.656/98. Pede o deferimento de tutela de urgência a fim de que a ré forneça ou custeie a aquisição do medicamento, a a concessão da gratuidade da justiça e, ao final, requer a procedência da ação.

Indeferida a gratuidade de justiça (evento 7, DESPADEC1), deferido o parcelamento da Taxa Única de Serviços Judicias (evento 11, DESPADEC1).

Deferida a tutela de urgência (evento 18, DESPADEC1).

Contestando (evento 27, CONT1), a ré apresenta, preliminarmente, impugnação ao valor da causa, pois o indicado não corresponderia ao que visa a ação, devendo ser atribuído à causa o valor de alçada, nos termos do que dispõe o artigo 292, § 3º, do Código de Processo Civil, ou devendo ser procedida a juntada de dois orçamentos da medicação objeto da lide, no intuito de apurar o menor valor praticado no mercado para fins de retificação/fixação do valor da causa. No mérito, argui a desconformidade do caso em tela com a diretriz de utilização nº 65 da rn nº 465/2021, alegando legitimidade da negativa ao medicamento Tezepelumabe 210 mg. Destaca que o artigo 10, inciso VI, da Lei n° 9656/98, há exclusão expressa do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar/ambulatorial, salvo em caso de tratamento de câncer e de internação domiciliar. Defende, ainda, que o CID não está listado na relação de doenças para as quais a cobertura do tratamento imunobiológico é obrigatória e sequer tendo a autora produzido prova da eficácia do mesmo para o seu quadro clínico. Colaciona jurisprudência que entende deva ser considerada pelo juízo no julgamento da causa e pede, ao final, a improcedência da ação.

Réplica no evento 33, RÉPLICA1.

É o relatório. Decido.

II – A lide comporta julgamento no estágio procedimental em que se encontra o processo, ainda que versadas questões de direito e de fato, porquanto a prova documental carreada aos autos é suficiente para solver a controvérsia, precipitação de julgamento levada a efeito com fundamento no artigo 355, inciso I, do CPC.

Procede a ação.

De início, rejeito a preliminar de impugnação ao valor da causa, pois corretamente atribuído se considerada a importância estimada para custeio do medicamento ao longo de um ano, correspondendo ao objeto da ação.

Na sequência, tem-se que as regras consumeristas são aplicáveis aos contratos de Plano de Saúde, em atenção à Súmula 608 do STJ *(Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.)*, devendo a relação ser interpretada da forma mais favorável ao consumidor, nos termos da norma contida no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, e não pode ser desconsiderada a própria finalidade do seguro-saúde, obviamente consubstanciada em que seja garantida a saúde do segurado em sua plenitude, nos exatos termos do objetivado pela Lei nº 9.656/98.

Quanto ao mérito propriamente dito, não há nenhuma dúvida no tocante ao fato de que o contrato de seguro é bilateral, ensejando direitos e obrigações para ambos os contraentes. O contrato, ainda, tem força vinculante entre os contraentes, não podendo, pois, ser alterado apenas pela vontade de uma das partes. Se assim fosse permitido, admitir-se-ia que qualquer delas pudesse libertar-se *ad nutum* do liame obrigacional, sendo que resulta necessária a preservação do adequado equilíbrio entre as partes, pena de ocorrência de lesão a qualquer delas.

E o equilíbrio contratual deriva, à evidência, das próprias cláusulas contratuais, que retratam a existência do negócio jurídico efetivado em todos os seus aspectos, no que diz com a titulação de direitos e o suporte de encargos, ou seja, diz com a observância do pactuado em seus termos, pena de ocorrência de lesão a qualquer dos contratantes, e, por outro lado, quanto a necessária interpretação e integração contratual, merece observância o ensinamento de Maria Helena Diniz, consoante segue:

1. Interpretação e integração contratual

Como todo negócio jurídico, o contrato origina-se de ato volitivo, com o escopo de obter um certo objetivo, criando, com base em norma jurídica, direito subjetivo, e impondo, por outro lado, obrigações jurídicas.

Essa declaração de vontade requer sempre uma interpretação, dado o fato da possibilidade do negócio jurídico conter cláusula duvidosa, qualquer ponto obscuro ou controvertido. A tarefa do intérprete do contrato encontrará uma série de dificuldades, pois além de analisar o texto contratual, deverá examinar a intenção comum dos contratantes. A atividade interpretativa do contrato é uma operação difícil, que requer saber e prudência, devendo o intérprete guiar-se pelo sentimento jurídico, que o impedirá de cair em interpretações alheias à vida. A interpretação contratual poderá ser declaratória, se tiver por único móvel a descoberta da intenção das partes interessadas no momento da realização do contrato, ou construtiva, se objetivar a reconstrução do ato negocial, possibilitando assim a produção de seus efeitos.

A interpretação situar-se-á na seara do conteúdo da declaração volitiva, fixando-se em normas empíricas, mais de lógica prática do que de normação legal, pois a legislação contém tão-somente algumas normas interpretativas:

.....

A integração contratual vem a ser um processo lógico-sistemático que possibilitará preencher lacunas encontradas nos contratos, complementando-os por meio de normas supletivas, emitidas pelo poder competente.

Os autores italianos, baseados no Código Civil italiano, arts. 1.339 e 1.440, denominam tal processo de integrativo.

A interpretação contratual terá por escopo determinar o conteúdo contratual duvidoso, buscando seu verdadeiro sentido, eliminando ambiguidades, dúvidas ou contradições, resultantes do texto do contrato.

A integração contratual, por sua vez, pretenderá desvendar os efeitos do contrato, nas hipóteses em que apresentarem falhas ou lacunas, em decorrência de ausência de previsão ou conhecimento das partes contratantes ou de não correspondência do contrato a fatos ou valores não supridos pela via interpretativa. A integração contratual seria, portanto, um modo de aplicação jurídica feita pelo órgão judicante, mediante o recurso à lei, à analogia, aos costumes, aos princípios gerais de direito ou à equidade, criando norma supletiva, que completará, então, o contrato, que é uma norma jurídica individual. Logo, com a aplicabilidade dos arts. 4º e 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, ter-se-á a colmatação da lacuna contratual, no caso sub judice. (Maria Helena Diniz, Tratado Teórico e Prático dos Contratos, vol. I, p. 81/84)

Na hipótese em exame, no entanto, não há dúvida de que o contrato foi firmado sem que a demandante restasse possibilitada a discussão das cláusulas contratuais em seus termos, eis tratar-se de verdadeiro contrato de adesão, padronizado e previamente impresso.

Ocorrida a contratação nos termos antes explicitados, portanto, resulta a ocorrência de situação fática a determinar a necessidade de ser emprestada interpretação mais favorável à requerente das cláusulas contratuais, nos exatos termos do disposto no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que, por outro lado, não pode ser desconsiderada a própria finalidade do seguro-saúde, obviamente consubstanciada em que seja garantida a saúde do segurado em sua plenitude, nos exatos termos do objetivado pela Lei nº 9.656/98 (Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, de 03.06.98), a qual, por exemplo, no artigo 35-C (com a redação dada pela Lei n. 11.935/2009), veda a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação, e, em seu artigo 12, § 2º, determina:

É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

Ora, presente a determinação legal de fornecimento de cobertura em casos de emergência, vigente à época em que ocorreu o fato envolvendo a autora, bem assim considerado que o seguro-saúde tem por finalidade primeira garantir a saúde do segurado em todas as situações de patologia, resulta a conclusão sobre a indevida negativa de cobertura securitária.

No mais, entendido o caráter abusivo, de iniquidade da cláusula contratual e tendo em conta que os artigos 10 e 12 da Lei 9.656/98 estabelecem faculdades às operadoras de plano de saúde, devendo ser interpretados de forma sistemática com a regra antes referida, certo é que deve ser proclamada a sua insubsistência, a teor do que dispõe o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, e, em consequência, há que ser reconhecido o encargo da demandada em fornecer a devida cobertura à segurada.

Por fim, merece destaque o seguinte norte jurisprudencial:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. QUIMIOTERAPIA VIA ORAL. NEXAVAR. MEDICAMENTO FORA DO ÂMBITO HOSPITALAR. Hipótese em que a negativa de fornecimento do medicamento denominado Sorafenib (Nexavar), sob a alegação de se tratar de tratamento domiciliar, não se sustenta. Os planos de saúde podem estabelecer quais as doenças que serão cobertas, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser alcançado ao paciente. Ademais, a parte autora demonstrou a emergência ou urgência na realização do procedimento realizado. Aplicabilidade dos arts. 47 e 51, IV do CDC, bem como do artigo 35-C, I, da Lei 9.656/98. Precedentes desta Corte. RECURSO ADESIVO - Majoração dos honorários advocatícios. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados consoante apreciação equitativa do Juiz, nos termos do art. 20, §4º do CPC, atendidos os parâmetros estabelecidos no §3º do mesmo dispositivo legal. Honorários mantidos. RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70035916345, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 15/12/2010)

Ademais, como atestado (evento 1, DOC5), documento no qual foi salientado por especialista que a não utilização do medicamento Tezepelumabe e desde que se "mantenha o quadro de crises frequentes está associado ao risco de óbito em situação de broncoespasmo e hipoxemia severa" - resulta viabilizado o acolhimento do pedido formulado pela autora, ao efeito de que a ré forneça cobertura securitária objetivada pela demandante, consubstanciada no fornecimento do medicamento "Tezepelumabe 210 mg SC (ampola) a cada 4 semanas, de forma contínua".

Há 1 ano está utilizando formoterol + beclometasona + glicopirronico, montelucaste, roflumilaste e azitromicina. Desde então sem hospitalizações, porém mantem sintomas recorrentes (com uso de broncodilatador de alívio diariamente) e exacerbações a cada 2 meses. Apresenta uma asma extremamente lábil com marcada hiperreatividade (broncoespasmo em todas as espirometrias) e oscilação do pico de fluxo expiratório ao longo dos dias.

E não merece prosperar o argumento da ré no que se refere à listagem da relação de doenças para as quais a cobertura do tratamento imunobiológico é obrigatória, pois é medicamento com indicação em bula para tratar o CID apresentado.

A demandada alega, ainda, a ausência de recomendações pela CONITEC ou de no mínimo um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional e esteja aprovada para seus nacionais, conforme previsto em Lei. Porém, consta o medicamento no relatório de recomendação nº 613 de maio de 2021 (https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2021/20210602_relatorio_613_benralizumabe_mepolizumabe_asma_grave_p_22.pdf) pela CONITEC, com informações fornecidas pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos em Saúde e demais.

Ademais, não pode ser olvidado estar o direito à vida guindado à condição de absoluto e mesmo porque sequer pode ser negado o atendimento em situações de emergência ou urgência, consoante estabelece o artigo 35-C da Lei n. 9.656/98, com a redação que lhe foi dada pela Medida Provisória n. 2.1777-44/01, e, por outro lado, o pleito formulado pela autora encontra amparo no artigo 12, inciso I, letra b, da lei antes mencionada, assim redigida:

> *Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:* ***(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)***
>
> *I - quando incluir atendimento ambulatorial:*
>
> .....
>
> *b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;* ***(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)***

Dessa forma, deve a ré fornecer a cobertura necessária ao tratamento da autora, relevando ser destacado que deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual.

Impõe-se, pois, a procedência da ação.

III – FACE AO EXPOSTO, julgo procedente o pedido cominatório e condeno a ré ao fornecimento da cobertura securitária objetivada na inicial, consubstanciada no fornecimento do medicamento "Tezepelumabe 210 mg SC (ampola) a cada 4 semanas, de forma contínua, com a consequente manutenção da tutela de urgência antecipadamente deferida (evento 18, DESPADEC1). Condeno-a, por fim, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, com amparo no artigo 85, § 2º, do CPC.

Na fixação da verba honorária considerei o grau de zelo na elaboração das peças processuais, o local da prestação do serviço, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo necessário para sua realização, inclusive decorrente do necessário acompanhamento processual, eis que ajuizada a ação em 08/11/2023.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, dê-se baixa.

Documento assinado eletronicamente por **WALTER JOSE GIROTTO, Juiz de Direito**, em 16/2/2024, às 15:58:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10054580163v26** e o código CRC **6487bcea**.